



**Unidad Administrativa Especial Agencia del
Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales -ITRC**

ABANDONO INJUSTIFICADO DEL CARGO – Estructuración de la falta disciplinaria.

Para dilucidar este aspecto de la impugnación y verificar si existe o no un motivo de duda razonable, frente a la estructuración de la falta, debemos recordar cómo está definido el abandono de cargo, inicialmente en el Código Disciplinario Único, y luego, complementando el tipo, dentro de las normas de rango eminentemente administrativo.

La conducta por la cual se llamó a responder al procesado, aparece descrita por el legislador en el numeral 55 del artículo 48 del C. D. U., donde se consideró como falta gravísima "...el abandono injustificado del cargo, función o servicio. Como puede observarse, el precepto anterior, a pesar de que integra un elemento normativo en la configuración de la falta, como es la determinación del injusto, no define con suficiencia en qué consiste realmente el abandono del cargo. Fue por esta razón que acertadamente, tanto en el auto de citación a audiencia, como en el fallo apelado, se complementó la norma disciplinaria con el Decreto 1950 de 1973, por el cual se reglamentan los Decretos- Leyes 2400 y 3074 de 1968 y otras normas sobre administración del personal civil.

El artículo 126 de la norma en mención define expresamente el abandono de cargo, en los siguientes términos:

"...Artículo 126.- El abandono del cargo se produce cuando un empleado sin justa causa:

1. No reasume sus funciones al vencimiento de una licencia, permiso, vacaciones, comisión, o dentro de los treinta (30) días siguientes al vencimiento de la prestación del servicio militar. ...".
2. Deje de concurrir al trabajo por tres (3) días consecutivos.".

Cualquiera de estas dos situaciones constituye abandono del cargo y por lo tanto es causal de retiro del servicio para la Administración.

FUENTE FORMAL: LEY 734 DE 2002 - / ARTICULO 48, NUMERAL 55.

Dependencia:	Dirección General
Número del Proceso:	1704-01-2013-100
Número y fecha del fallo:	00006 del tres (3) de mayo de dos mil trece (2013)
Asunto:	Fallo de segunda instancia
Criterio de Selección:	Fallo de primera instancia confirmado en segunda instancia.



Continuación de la Resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario ITRCNo. 170100-2013-001.

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede el despacho a resolver el recurso de apelación interpuesto por el abogado (XXX), en su condición de defensor del procesado (XXX), contra el fallo sancionatorio proferido en audiencia, celebrada y dirigida por el Subdirector de Gestión de Control Disciplinario Interno de la DIAN, el pasado 5 de febrero de 2013.

COMPETENCIA

La suscrita Directora General de la Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales – ITRC, es competente para resolver la presente impugnación, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto 4173 de 2011, aclarado por el Decreto 4452 de 2011, en atención a las previsiones contenidas en los numerales 12 y 13 del artículo 3° del Decreto 00985 del 14 de mayo de 2012, y al contenido del artículo 171 de la Ley 734 de 2002.

Adicionalmente, se asume esta función y competencia disciplinaria, de conformidad con la designación de Directora General Ad hoc, de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, realizada por el Ministro de Hacienda y Crédito Público, mediante Decreto 0461 del 14 de marzo de 2013.

HECHOS Y ANTECEDENTES PROCESALES

1.- La presente actuación disciplinaria tuvo su origen en el informe presentado por el señor (XXX), Jefe de la Coordinación de Inventarios y Almacén de la DIAN, a través del aplicativo Vigía, fechado el 11 de agosto de 2011. En dicho documento, el funcionario mencionado puso de presente la presunta ausencia laboral injustificada del servidor (XXX), Facilitador III asignado a la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos de la DIAN, durante los días 15, 18 y 19 de julio de 2011. Ver fl. 1 del c. o.

2.- Por los hechos relatados en el numeral precedente, la Subdirección de Gestión de Control Disciplinario Interno de la DIAN, mediante auto datado el 25 de octubre de 2011, dispuso la apertura de indagación preliminar contra el funcionario (XXX). Esta decisión fue notificada personalmente al funcionario implicado el 5 de noviembre de 2011. Ver fls. 7 y 37 del c. o.

3.- Habiéndose cumplido el término de la indagación preliminar, lapso durante el cual se decretaron y practicaron pruebas documentales, la Coordinación de instrucción de la Subdirección de Gestión de Control Disciplinario Interno dispuso, mediante auto signado el 10 de mayo de 2012, variar el procedimiento ordinario hasta ese momento adelantado, para continuar, en su lugar, con los trámites propios del procedimiento verbal. Lo anterior teniendo en cuenta que la conducta investigada tendría posible adecuación dentro de la falta disciplinaria consagrada en el numeral 55 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. Ver fl. 119 del c. o.

4.- Como consecuencia de la anterior decisión, la misma Subdirección de Gestión de Control Disciplinario Interno de la DIAN, como despacho de primer grado, profirió Auto de Citación a Audiencia, el 22 de mayo de 2012, llamando a responder disciplinariamente al procesado (XXX),

Continuación de la Resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario ITRCNo. 170100-2013-001.

por el presunto abandono de cargo. Esta decisión fue notificada personalmente al procesado y a su defensor, los días 29 y 31 de mayo de 2012, respectivamente. Ver fls. 120 a 139 del c. o.

5.- Con auto del 1° de junio de 2012 el funcionario de primer grado señaló el día 14 del mismo mes y año, para dar inicio a la Audiencia del proceso Verbal. Esta decisión fue comunicada a los sujetos procesales.

6.- El 14 de junio de 2012, la primera instancia debió aplazar el inicio de la audiencia, a petición de los sujetos procesales, fijando nueva fecha para el 4 de julio de 2012.

7.- Llegado el 4 de julio de 2012 el funcionario a quo se constituyó en Audiencia y dio inicio al juicio verbal correspondiente, con la presencia de los sujetos procesales, el implicado y su defensor de confianza. En esta sesión inicial, el procesado rindió versión sobre los hechos objeto de reproche. Acto seguido los sujetos procesales solicitaron la práctica de pruebas testimoniales y documentales, algunas de las cuales fueron denegadas por el director de la audiencia, situación que generó la interposición de los recursos de reposición y apelación por parte de la defensa. El auto de pruebas no se repuso por parte del juez de instancia, quien subsidiariamente concedió el recurso de apelación ante el superior, suspendiendo la audiencia, para continuarla el día 18 de julio de 2012.

8.- La impugnación contra el decreto de pruebas fue resuelta desfavorablemente al apelante, mediante decisión calendada por el Director General de la Dian el 13 de julio de 2012, en la cual se confirmó totalmente el rechazo de las pruebas pretendidas por la defensa. Dicha decisión de segundo grado fue notificada en estrados a los sujetos procesales, el 18 del mismo mes y año, fecha en que se reanudó la audiencia, dándose inicio a la práctica de las pruebas testimoniales decretadas. En esta oportunidad se recaudó el testimonio del ciudadano (XXX). Ante la imposibilidad de contar con la presencia del procesado, detenido en la Cárcel Nacional Picota, de esta ciudad, se suspendió el desarrollo de la audiencia, fijándose el 2 de octubre de 2012 como fecha para su continuación. Ver fls. 172 a 176 del c. o.

9.- Con auto calendado el 31 de agosto de 2012 y a solicitud del abogado defensor, el despacho a quo reprogramó la continuación de la audiencia para el día 13 de septiembre de 2012, fecha en la cual fue necesario aplazar una vez más el desarrollo del proceso, por la inasistencia de los sujetos procesales. Ver fl. 203 del c. o.

10.- Mediante decisión fechada el 26 de noviembre de 2012, el funcionario a quo señaló el 7 de diciembre del mismo año, como fecha para continuar con la práctica de las pruebas testimoniales, decretadas en la audiencia. Ver fl. 216 del c. o.

11.- Llegado el día y hora prefijados, una vez más se hizo constar la inasistencia de los sujetos procesales, razón por la cual se señaló el 17 de diciembre del 2012, a las 9:00 a.m., como fecha y hora para reanudar la vista pública. En esta nueva oportunidad, fue imposible continuar con el trámite procesal, debido a la ausencia del abogado defensor, quien presentó las justificaciones del caso. En consecuencia, el despacho procedió a fijar, mediante auto del 10 de enero de 2013, el 17 de enero subsiguiente, para reanudar la audiencia de pruebas. Ver fl. 250 del c.o.

12.- en sesión de audiencia pública celebrada el 17 de enero de 2013 se recaudó el testimonio del servidor (XXX), con la presencia de los sujetos procesales, quienes tuvieron la oportunidad de controvertir dicho testimonio. El despacho de primera instancia declaró concluida la etapa probatoria del juicio y suspendió la audiencia por unas horas, para recibir los alegatos de conclusión, por parte de la defensa. Ver fls 262 a 268 del c. o.

Continuación de la Resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario ITRCNo. 170100-2013-001.

13.- Con fecha 5 de febrero de 2013, el juez disciplinario de primer grado se constituyó en audiencia, con el fin de dar lectura al fallo de instancia. En esta oportunidad se declaró la responsabilidad disciplinaria del procesado, imponiéndosele como sanción, Destitución e inhabilidad general por el término de doce años. El fallo aludido fue apelado inmediatamente por el abogado defensor, razón por la cual se concedió la alzada, en el efecto suspensivo, ante el señor Director General de la DIAN, doctor (XXX), quien simultáneamente con la impugnación fue recusado por el apelante.

13.- Como consecuencia del trámite propio de la recusación, el Ministro de Hacienda y Crédito Público expidió el Decreto 0461 del 14 de marzo de 2013, a través del cual designó a la suscrita servidora, como Directora General de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, ad hoc, para resolver el recurso de apelación interpuesto contra el fallo de primera instancia.

14.- Mediante auto fechado el 1° de abril del año en curso, este despacho avocó el conocimiento de la actuación disciplinaria y dio aplicación al inciso séptimo del artículo 180 del C. D. U., modificado por el artículo 59 de la Ley 1474 de 2011, corriendo traslado a los sujetos procesales, apelantes y no apelantes, por el término de dos (2) días, para presentar alegatos finales frente al recurso de apelación. El auto fue notificado a los sujetos procesales por Estado N° 033 del 12 de abril de 2013. El traslado pertinente se surtió durante los días 15 y 16 de abril de 2013, Término durante el cual los sujetos procesales se abstuvieron de hacer uso de la respectiva oportunidad para presentar alegatos de conclusión en segunda instancia.

FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN IMPUGNADA

Antes de iniciar las consideraciones propias de la instancia, el funcionario a quo incluyó algunos párrafos o acápites que resumen y transcriben, la conducta objeto de investigación, el cargo formulado en la Citación a Audiencia y los argumentos defensivos de los procesados, planteados a lo largo del juicio, en sus versiones y alegaciones finales.

Inmediatamente, la primera instancia inició sus motivaciones citando la normatividad que le atribuye competencia legal para fallar el caso sub exámine. A renglón seguido se nombran en el fallo impugnado los preceptos legales que describen, en materia disciplinaria, la exigencia probatoria mínima para sancionar y el sistema de valoración o apreciación probatoria.

En un acápite titulado como "CASO CONCRETO", el juzgador de primer grado inició el análisis detallado de las pruebas documentales y testimoniales que soportaron su decisión sancionatoria. Como primera medida, determinó el despacho de instancia los límites temporales en que se pudo perpetrar el abandono del cargo, por parte del disciplinado. Al respecto, señaló el a quo que si bien, la actuación se inició con el fin de establecer las ausencias del disciplinado ocurridas durante los días 15, 18 y 19 de julio de 2011, en desarrollo del juicio se pudo establecer que el día 15 de julio el implicado estaba incapacitado médicamente y que, por lo tanto, la conducta objeto de reproche obedeció al hecho de no haberse reintegrado a sus labores a partir del 18 de julio de 2011, situación que se prolongó incluso durante los días 21, 22 y 29 de julio del mismo año, según lo demuestran los diferentes oficios expedidos por el jefe inmediato del disciplinado y por la Subdirección de Gestión de Personal, evidenciando el comportamiento del acusado. Concluyó el despacho de primer grado que desde estos días y hasta el 1°. De agosto de 2011, fecha en que finalmente el

Continuación de la Resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario ITRCNo. 170100-2013-001.

procesado se sometió a la justicia, en cumplimiento a una orden judicial, el encartado desatendió sus obligaciones laborales al ausentarse injustificadamente de su lugar de trabajo.

Continuando con el análisis probatorio, esta vez frente a la prueba testimonial allegada, rechazó el fallador de instancia los argumentos defensivos del procesado, al pretender justificar su ausencia laboral, con la realización de supuestos trámites administrativos, relacionados con la concesión de un permiso y una licencia no remunerada. Al respecto, señaló enfáticamente el a quo que el dicho del investigado fue desvirtuado con la declaración jurada de su inmediato superior, quien no solo desconoció la existencia de las aludidas peticiones, por parte de su subordinado, sino que además resaltó el hecho de que el implicado conocía muy bien los procedimientos establecidos al interior de la DIAN para tramitar y obtener las situaciones administrativas.

Las motivaciones subsiguientes del fallo apelado estuvieron orientadas a desvirtuar las razones de justificación de la conducta del disciplinado, esgrimidas por la defensa técnica: En una primera consideración, rechazó el fallador de instancia la causal de fuerza mayor o caso fortuito, alegada por el procurador del enjuiciado, quien aseguró que su representado dejó de asistir a su puesto de trabajo, por encontrarse en su condición de “prófugo de la justicia”, situación calificada como hecho notorio o de público conocimiento para la DIAN. Al respecto, el a quo expresó que la simple expedición de la orden de captura no puede ser tenida como condición de fuerza mayor o causal impeditiva para asistir a trabajar, pues no existe una privación efectiva o material de la libertad, la cual, en el caso presente, solamente se cumplió hasta el 1° de agosto de 2011. Agregó la primera instancia que el procesado tuvo conocimiento de la orden de captura proferida en su contra, desde el 14 de julio de 2011 y desde esta fecha hasta los días en que se hizo efectiva su entrega voluntaria y posterior detención (1 y 3 de agosto de 2011), tuvo el tiempo necesario para decidir, voluntariamente su entrega a la justicia y determinarse simultáneamente a no comparecer a su lugar de trabajo.

Con un amplio referente al estudio y posición jurisprudencial sobre el concepto de libertad personal, sus límites y garantías, el fallador de primer grado rechazó el argumento de la defensa, pues aseveró que en el presente caso, no se encuentran presentes las condiciones de irresistibilidad e imprevisibilidad de la causal de exclusión de responsabilidad.

Con relación al argumento defensivo de actuar en cumplimiento de un deber legal o constitucional de mayor importancia que el sacrificado, señaló el juez a quo que el cumplimiento del deber ciudadano de sometimiento a la justicia, se verificó cuando ya había asumido el procesado su decisión voluntaria de no reintegrarse a sus labores al vencimiento de la incapacidad médica, habiéndose configurado antes el abandono del cargo.

Frente a la causal 3 del artículo 28 del C. D. U., invocada por la defensa, el operador de primer grado rechazó el planteamiento precisando que: “...la no presentación a laborar del aquí procesado, en absoluto fue el resultado del cumplimiento de una orden legítima de autoridad competente. No puede confundirse el hecho de que una autoridad judicial expida la orden de captura o de llamamiento a proceso penal respecto de una persona en quien simultáneamente concurre la condición de servidor público, con la decisión deliberada de éste de no presentarse a laborar, so pretexto de que pretendía cumplirla. ...” Adicionalmente señaló: “...Esta causal de exclusión de responsabilidad alegada por la defensa, técnicamente está mal utilizada, pues ella se concibió para explicar que no hay lugar a reproche disciplinario, cuando alguien procede atendiendo una orden legítima emitida por autoridad competente, esto es, cuando obra exactamente de la manera en que la orden le indica que lo haga. Así haciendo aplicación correcta de la causal, resulta por lo menos irrazonable en un caso como el que se estudia, pretender que un Fiscal conminó al funcionario investigado a que se ausentara del puesto de trabajo y abandonara su cargo. ...”.

Continuación de la Resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario ITRCNo. 170100-2013-001.

Manteniendo total coherencia o ilación frente a las motivaciones precedentes, que lo llevaron a rechazar los argumentos defensivos del procesado y su defensor, el fallador de instancia consideró que las pruebas allegadas al juicio demuestran, en grado de certeza, la comisión de la falta objeto de citación a audiencia y la responsabilidad del disciplinado. Artículo 142 del C. D. U.

Seguidamente, el funcionario aquo orientó sus consideraciones a demostrar la presencia de los elementos estructurantes de la falta disciplinaria, tales como la tipicidad, la ilicitud sustancial y la culpabilidad. Mantuvo entonces la calificación jurídica de la falta, realizada en el auto de citación a audiencia, al señalar que el procesado, al no reasumir funciones, al vencimiento de su incapacidad, el 18 de julio de 2011, incurrió en la falta gravísima de abandono de cargo prevista en el numeral 55 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, en armonía con el artículo 126 del Decreto 1950 de 1.973. De la misma manera ratificó la imputación subjetiva, al considerar que el comportamiento del disciplinado fue realizado a título de Dolo, por estar presentes en él los aspectos cognoscitivos y volitivos que definen dicha figura jurídica.

Finalizando sus consideraciones, el fallador de instancia acudió a los criterios de graduación de la sanción, previstos en el artículo 47 del C. D. U., encontrando, en favor del procesado, la ausencia de antecedentes disciplinarios; la no afectación de derechos fundamentales; el no pertenecer a un cargo directivo; y el conocimiento en torno a la ilicitud de la conducta. Con estas premisas consideró el a quo que la sanción a imponer al procesado no podía ser otra que la Destitución e Inhabilidad General por el término de Doce años.

SUSTENTACIÓN DEL RECURSO

Dentro de la oportunidad procesal pertinente, esto es, en desarrollo de la misma audiencia de fallo, el defensor de confianza del procesado presentó y sustentó su recurso de apelación contra el fallo sancionatorio de primera instancia, con base en los siguientes planteamientos:

1.- La defensa técnica del disciplinado, inició la sustentación del recurso, haciendo una crítica a la valoración que el despacho de primer grado realizó frente al testimonio del servidor (XXX), quien para la época de los hechos fungió como jefe inmediato del procesado. Según el impugnante, entre dicho testimonio y la prueba documental obrante a folio 4 del c. o, consistente en el oficio que signara el mismo declarante ante la Subdirección de Gestión de Personal, reportando la ausencia del disciplinado, existe una contradicción y surge una duda razonable que debe ser resuelta en favor de su cliente. La duda que pretende configurar el togado, se refiere al hecho de afirmar que la Administración, a través del superior inmediato del investigado, sabía de antemano su intención de tramitar un permiso o una licencia, situaciones administrativas que, según su dicho, no logró materializar, ante su decisión voluntaria de someterse a la justicia.

2.- En las líneas subsiguientes del recurso, el impugnante planteó, de manera bastante densa o difusa, su oposición a los argumentos que llevaron al fallador de instancia a rechazar la aplicación de las causales de exclusión de responsabilidad, previstas en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 28 del C. D. U. Sobre el particular, la argumentación del recurrente se limitó a calificar los argumentos del fallador de instancia como "errados", "inciertos" o "...descontextualizados", sin ampliar las razones de su manifestación.

Continuación de la Resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario ITRCNo. 170100-2013-001.

3.- En una idea inicial, el apelante intentó demostrar que a pesar de haberse librado la orden de captura de su defendido, desde los días 13 y 14 de julio de 2011, por razones ajenas a su voluntad dicha medida solo se materializó durante los días 15 de julio y 1° de agosto de 2011, con la entrega voluntaria del procesado a la DIJIN. Argumentó que nunca fue voluntad de su cliente, que el ente investigador y el juez con control de garantías hayan desarrollado la audiencia de imputación de cargos, solamente hasta los días 2 y 3 de agosto de 2011. Con este planteamiento el apelante aseveró que: "...la entidad ciegamente se niega a desconocer un sometimiento a la justicia desde el día 15 de julio de 2011 por parte de (XXX) dentro de un proceso penal 20110025, y que sus diferentes actuaciones lo eximen de un dolo o de culpa, porque se confunde este sometimiento con una materialización de una orden de captura no tendrá cabida ningún argumento de la defensa ya que la administración ha sido terca y unánime como lo demostró en las resoluciones que declararon la vacancia del cargo por abandono 010165 y 012384, ambas proferidas por el Director de esta entidad, en el cual desde dicha época se pusieron de presente los mismos hechos que no pueden ser otros que los reales, los ocurridos en este proceso disciplinario, será insuficiente cualquier esfuerzo de parte de este defensor frente a una administración que ha sido implacable con los intereses de (XXX), ...". Con esta afirmación, reiteró el recurrente su intención a fin de que se declare la exclusión de responsabilidad disciplinaria de (XXX) de conformidad con lo previsto en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 28 del C. D. U.

4.- En resumen, fueron estos los planteamientos por los cuales el defensor solicitó la revocatoria del fallo apelado, en su integridad, profiriéndose en su lugar una decisión que declare que: "... (XXX) no es responsable disciplinariamente conforme a la descripción típica de la falta disciplinaria gravísima contenida en el numeral 55 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 y como consecuencia de la anterior revocatoria se levante la imposición de la sanción disciplinaria impuesta consistente en destitución e inhabilidad general por el término de 12 años...".

ALEGACIONES EN SEGUNDA INSTANCIA

El término de traslado para alegar de conclusión en segunda instancia, transcurrió en silencio por parte de los sujetos procesales, quienes no hicieron uso de tal oportunidad procesal.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Antes de dar inicio a estas consideraciones, es importante recordar al impugnante que de conformidad con la previsión legal consagrada en el párrafo del artículo 171 de la Ley 734 de 2002, "...El recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de la impugnación. ...".

Pese a los genéricos y abstractos argumentos que presenta el impugnante, el despacho procederá a revisar el fallo apelado, teniendo en cuenta las difusas razones de impugnación del recurrente.

Como primera medida, entrará el despacho a cotejar si efectivamente, tal como lo concluyó el despacho de instancia, se encuentran reunidos los requisitos probatorios mínimos necesarios para proferir un fallo sancionatorio, previstos en el artículo 142 de la ley 734 de 2002, bajo el siguiente tenor literal:

Continuación de la Resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario ITRCNo. 170100-2013-001.

“...Artículo 142. Prueba para sancionar. No se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado. ...”.

Lo anterior teniendo en cuenta que el argumento inicial y fundamental del apelante, está enfocado en demostrar una posible duda razonable, relacionada con la estructuración de la falta objeto de sanción, la cual, en su concepto, debe ser resuelta a favor de su defendido. Tal como lo expresamos en el resumen de la impugnación, el recurrente anunció una supuesta contradicción proveniente de la valoración probatoria realizada al testimonio del servidor (XXX), la cual riñe con la realidad probada en el oficio visible a folio 4 del c. o., donde el mismo declarante, en su condición de jefe inmediato del disciplinado, puso en conocimiento de la Subdirección de Gestión de Personal, el presunto abandono de cargo en que había incurrido el subalterno investigado. Con lo anterior, pretende significar el autor de la alzada, que la administración, a través del superior inmediato del investigado, conocía con antelación la intención que éste tuvo de tramitar un permiso o una licencia, situaciones administrativas que, según su dicho, estarían llamadas a justificar la ausencia del procesado.

Para dilucidar este aspecto de la impugnación y verificar si existe o no un motivo de duda razonable, frente a la estructuración de la falta, debemos recordar cómo está definido el abandono de cargo, inicialmente en el Código Disciplinario Único, y luego, complementando el tipo, dentro de las normas de rango eminentemente administrativo.

La conducta por la cual se llamó a responder al procesado, aparece descrita por el legislador en el numeral 55 del artículo 48 del C. D. U., donde se consideró como falta gravísima “...el abandono injustificado del cargo, función o servicio. Como puede observarse, el precepto anterior, a pesar de que integra un elemento normativo en la configuración de la falta, como es la determinación del injusto, no define con suficiencia en qué consiste realmente el abandono del cargo. Fue por esta razón que acertadamente, tanto en el auto de citación a audiencia, como en el fallo apelado, se complementó la norma disciplinaria con el Decreto 1950 de 1973, por el cual se reglamentan los Decretos- Leyes 2400 y 3074 de 1968 y otras normas sobre administración del personal civil.

El artículo 126 de la norma en mención define expresamente el abandono de cargo, en los siguientes términos:

“...Artículo 126.- El abandono del cargo se produce cuando un empleado sin justa causa:

1. No reasume sus funciones al vencimiento de una licencia, permiso, vacaciones, comisión, o dentro de los treinta (30) días siguientes al vencimiento de la prestación del servicio militar. ...”.
2. Deje de concurrir al trabajo por tres (3) días consecutivos.”.

Cualquiera de estas dos situaciones constituye abandono del cargo y por lo tanto es causal de retiro del servicio para la Administración.

En el caso que nos ocupa, el comportamiento objeto de reproche al disciplinado estuvo siempre enfocado al hecho de no haberse reintegrado a sus funciones, al vencimiento de una incapacidad médica concedida el 15 de julio de 2011, situación que debió verificarse el 18 de julio del mismo año.

Continuación de la Resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario ITRCNo. 170100-2013-001.

Las motivaciones del auto de citación a audiencia y del fallo apelado, afirman de manera conteste que el abandono del cargo se configuró precisamente el 18 de julio de 2011, cuando el procesado se abstuvo de reintegrarse a sus funciones, una vez cumplida su incapacidad, prolongándose dicho comportamiento en el tiempo, si se tiene en cuenta que transcurrieron más de tres días sin lograrse la presencia y reasunción de funciones por parte del disciplinado.

Desde este momento debe afirmar este despacho ad quem, que comparte la valoración probatoria que llevó al fallador de primer grado a afirmar con certeza que existió la conducta de abandono de cargo, en las circunstancias de tiempo ya conocidas.

Son abundantes las pruebas que soportan el ausentismo del procesado, a partir del 18 de julio de 2011:

Inicialmente aparecen en el proceso, como hechos originarios de la actuación, los oficios a través de los cuales el propio superior inmediato del disciplinado, reportó la ausencia laboral del investigado, ante la Subdirección de Control Disciplinario Interno y ante la Subdirección de Gestión de Personal, el 9 de agosto y el 21 de julio de 2011, respectivamente.

Igualmente obra como prueba documental que demuestra la inasistencia laboral del procesado, el requerimiento realizado por la propia Subdirección de Gestión de Personal, al procesado, fechado el 29 de julio de 2011, donde se le reclama una explicación por no haberse presentado a trabajar desde el 15 de julio.

En desarrollo de la actuación disciplinaria, se allegó el oficio 1.0.206.215.315.405 del 18 de noviembre de 2011, a través del cual el propio jefe inmediato del procesado, manifestó que dicho servidor no se presentó a trabajar después del 19 de julio de 2011. En esta misma oportunidad se allegó a la actuación el reporte de control de horario, donde se evidencia una vez más la inasistencia del implicado, desde el 18 de julio del 2011 hasta el 31 del mismo mes y año.

Pero no fue únicamente la prueba documental la que llevó al fallador de instancia a considerar probada, en grado de certeza, la falta objeto de sanción. Efectivamente, al pronunciarse sobre los argumentos defensivos expuestos por el disciplinado, como justificación a su actuar, el funcionario a quo debió acudir al análisis o valoración del testimonio ofrecido por (XXX), quien para la época de los hechos se desempeñó como jefe inmediato del procesado.

La valoración realizada por el operador disciplinario de primer grado, frente al aludido testimonio, resulta para este despacho ajustada a derecho. Sin lugar a dudas, la importancia de esa declaración radicaba en el hecho de poder probar las argumentaciones defensivas que fueron expuestas por el servidor implicado. Recuérdese que en ejercicio de su defensa material el investigado planteó como posible justificación el hecho de haber inasistido a su lugar de trabajo, amparado en un permiso indefinido, concedido por su jefe inmediato, vía telefónica, desde el 14 de julio de 2011.

En la lectura cuidadosa del citado testimonio, recaudado con la presencia y contradicción de los sujetos procesales, se puede concluir fácilmente, tal como lo hizo en su análisis el fallador aquo, que los aludidos planteamientos de justificación del procesado se tornan en simples razones defensivas, sin ningún viso de credibilidad o realidad. El dicho del testigo, frente a los hechos investigados, demuestra imparcial y objetivamente, que nunca existieron ni el permiso ni la licencia que fueron aludidos por el encausado. Como aporte adicional del testimonio, se demostró que las dos situaciones administrativas mencionadas, tienen al interior de la DIAN un trámite y una competencia específicos, ajenos por completo al desempeño funcional del testigo, razón de más para restar credibilidad a las argumentaciones defensivas del implicado.

Continuación de la Resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario ITRCNo. 170100-2013-001.

Aunque el testigo recordó haber recibido una llamada telefónica a su celular, realizada por el procesado, días antes de su ausencia laboral, situación que puede corresponder a la llamada que tanto la defensa técnica como el investigado afirman haberse realizado el 14 de julio de 2011, en horas de la mañana, el contenido de dicha conversación telefónica no tiene ninguna solidez frente al debate probatorio que aquí nos interesa. Enfáticamente aseveró el declarante que el señor (XXX) no le pidió nunca un permiso, pues simplemente le manifestó que tenía unos inconvenientes delicados, sin especificar cuáles o de qué tipo. Agregó el deponente que como respuesta a dicha manifestación simplemente le increpó a su interlocutor para que solucionara sus inconvenientes y estuviera informando lo pertinente. Agregó el testigo que con posterioridad a esta llamada nunca volvió a tener contacto con el disciplinado, siendo esta la razón por la cual en su oficio del 21 de julio de 2011, cumpliendo con su deber funcional, informó a la Subdirección de Gestión de Personal que el procesado no se presentó a trabajar los días 15, 18 y 19 de julio del mismo año, agregando que hasta esa fecha el funcionario "...no se ha comunicado con esta coordinación para informar algún tipo de inconveniente que le impida cumplir con la jornada laboral ...".

Desde el momento mismo en que se recibió el testimonio del servidor (XXX), es evidente que el defensor del enjuiciado pretendió controvertir la prueba haciendo notar algún tipo de contradicción entre el dicho del testigo y el contenido del oficio 10206215315-241, que obra al folio 4 del c. o. Sin embargo, atendiendo al análisis y valoración realizado por el funcionario aquo y ahora avalado o respaldado por esta instancia, resulta imperioso responder al profesional impugnante que este despacho de segundo grado no encuentra ningún tipo de contradicción entre la prueba testimonial y el documento aludidos, siendo en consecuencia igualmente inexistente la presunta "DUDA RAZONABLE" que ahora pretende plantear la defensa técnica en el desarrollo de esta alzada, para dar aplicación al principio procesal del IN DUBIO PRO DISCIPLINADO, consagrado en el inciso segundo del artículo 9 de la Ley 734 de 2002.

Con relación a los restantes argumentos del apelante, en los que, de manera difusa o poco clara, simplemente reitera los planteamientos de sus alegaciones finales, en el sentido de considerar que su representado actuó amparado en las causales de exclusión de responsabilidad previstas en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 28 de nuestro C. D. U. el despacho debe expresar que comparte y confirma íntegramente el juicioso estudio que realizó la primera instancia, para desvirtuar cada uno de los planteamientos exculpativos presentados por la defensa. Es importante recordarle al recurrente que el aquo, al construir el fallo impugnado, realizó una extensa motivación para fundar su rechazo frente a cada una de las causales alegadas. En consecuencia, no puede este despacho aceptar la afirmación del autor de la impugnación, cuando alude que la administración, "ciegamente", en forma "terca y unánime", se niega a admitir el sometimiento a la justicia de su cliente, como justificación de su actuar. Lo anterior si se tiene en cuenta que el impugnante no expresó cuáles fueron las razones de su inconformidad, frente al abundante fundamento negativo del fallador de instancia.

Las razones que llevaron al fallador de instancia a rechazar la aplicación de las causales de exoneración de responsabilidad alegadas por el defensor, resultan de una lectura o interpretación totalmente lógica, frente al desarrollo cronológico de los hechos objeto de debate. Veamos por qué:

Frente a la fuerza mayor o el caso fortuito, ciertamente las condiciones de imprevisibilidad e irresistibilidad de la figura justificativa desaparecen, si se tiene en cuenta que la orden de Captura se profirió desde el 14 de julio de 2011, mientras que la privación efectiva de la libertad, fruto del sometimiento voluntario del implicado a la justicia se cumplió a partir del 1 de agosto de 2011. Durante este lapso es que efectivamente se presentó el comportamiento de abandono del cargo.

Continuación de la Resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario ITRCNo. 170100-2013-001.

Se debe entender en este planteamiento que el procesado contó con un tiempo prudencial para que hubiera comunicado previamente su nueva situación jurídica a la administración, permitiendo así que se asumieran las situaciones administrativas que fueran del caso, a fin de no causar traumatismos en la función pública, derivados del abandono del cargo.

Este mismo planteamiento o análisis del desarrollo temporal de los acontecimientos, sirve de fundamento a esta instancia para afirmar, en total armonía con el fallador de primer grado, que en el momento en que el procesado optó por someterse efectiva y finalmente a la justicia – 1° de agosto de 2011- ya había igualmente obrado su decisión voluntaria de abandonar el cargo, desde el 18 de julio del mismo año, cuando no se reintegró a sus labores en la DIAN, siendo esta una razón lógica y legal para rechazar la aplicación de la causal de exclusión de responsabilidad prevista en el numeral 2 del artículo 28 del C. D. U.

Con relación a la causal del numeral 3 del artículo 28, varias veces mencionado, es innegable, tal como lo expresó el aquo, que el defensor dio una interpretación no técnica al precepto, al pretender demostrar que su prohijado abandonó el cargo, acatando una decisión emitida por una autoridad judicial penal.

Basten estas consideraciones para concluir que los argumentos del apelante no están llamados a prosperar y, por tanto deberán ser rechazados, confirmándose en su totalidad el auto impugnado, tal como se declarará en la parte resolutive de esta decisión.

Finalmente, como complemento de esta decisión y ante la vaguedad o generalidad de los argumentos planteados por el recurrente, es necesario recordarle lo que entiende nuestra jurisprudencia penal y disciplinaria sobre el deber procesal de sustentar una apelación o impugnación.

Sobre dicho tópico, nuestra Corte Suprema de Justicia -Sala Penal-, desde el auto del 11 de septiembre de 1984 enseñó : “..No constituye, por tanto, sustentación adecuada, el empleo de frases o expresiones en las cuales simplemente se manifiesta un desacuerdo genérico pero no se indican en concreto los aspectos que deben ser reformados o revocados por el superior, ni tampoco estará cabalmente sustentado el recurso que carezca de las razones, de tipo probatorio o jurídico que deben llevar a dicha reforma o revocatoria...”.

Para entender esa postura jurisprudencial, la misma Corte Suprema de Justicia ha precisado : “...Si la apelación es una faceta del derecho de impugnar, expresión ésta derivada de la voz latina impugnare, que significa “combatir, contradecir, refutar”, tiene que aceptarse que el deber de sustentar este recurso consiste precisa y claramente en dar o explicar por escrito la razón o motivo concreto que se ha tenido para interponer el recurso; o sea, para expresar la idea con criterio tautológico, presentar el escrito por el cual mediante la pertinencia crítica jurídica, se acusa la providencia recurrida a fin de hacer su contrariedad con el derecho y alcanzar por ende su revocatoria o su modificación”.

Y agrega tajantemente la misma corporación : “...Para no tolerar esguinces al precepto legal citado, y más precisamente para impedir que su razón finalística se quede en la utopía, cree la Corte que no pueda darse por sustentada una apelación, ni por ende cumplida la condición que subordina la admisibilidad de este recurso, cuando el impugnante se limita simplemente a calificar la providencia recurrida de ilegal, injusta o irregular; tampoco cuando emplea expresiones abstractas tales como “si hay prueba de los hechos”, “no están demostrados los hechos”, u otras semejantes, puesto que aquellos calificativos y estas expresiones, justamente por su vaguedad e imprecisión no expresan, pero ni siquiera implícitamente, las razones o motivos de la

Continuación de la Resolución por la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario ITRCNo. 170100-2013-001.

inconformidad del apelante con las deducciones lógico-jurídicas a que llegó el juez en su proveído impugnado” (Sala Penal Auto de agosto 30/84).

En tal virtud, la Directora ad hoc de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en uso de sus atribuciones legales,

RESUELVE:

PRIMERO. RECHAZAR las razones de impugnación invocadas por el defensor (XXX), de conformidad con los razonamientos expuestos en la parte motiva del presente proveído.

SEGUNDO. Como consecuencia de la anterior determinación, **CONFIRMAR TOTALMENTE** el fallo sancionatorio proferido en audiencia, el 5 de febrero de 2013, por el Subdirector de Gestión de Control Disciplinario Interno de la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a través del cual se sancionó con DESTITUCIÓN e INHABILIDAD GENERAL POR EL TÉRMINO DE DOCE (12) AÑOS, al servidor (XXX), por encontrarlo responsable de incurrir en la falta disciplinaria de abandono de cargo, cometida en las circunstancias de modo, tiempo y lugar allí mismo referidas.

TERCERO. NOTIFICAR el contenido de esta decisión a los sujetos procesales, de conformidad con las previsiones legales contenidas en los artículos 101,104 y 107de la Ley 734 de 2002.

CUARTO. Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

QUINTO. La presente decisión queda en firme el día de su suscripción, pero sus efectos jurídicos se surten a partir de la notificación, tal como lo dispone el inciso segundo del artículo 119 de la Ley 734 de 2002.

SEXTO. Una vez surtida la notificación del presente fallo, **REGISTRAR** La sanción disciplinaria ante la División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación, según lo ordena el artículo 174 de la Ley 734 de 2002, en armonía con el artículo 48, numeral 57 de la misma norma. Igualmente **REMITIR** copia de la presente decisión al Director General de la DIAN para que proceda, en su calidad de nominador, a ejecutar la sanción impuesta, de conformidad con lo establecido en el numeral 3º y PARÁGRAFO del artículo 172 del C. D. U.

SÉPTIMO. Ejecutoriada materialmente esta decisión y libradas las comunicaciones de ley, **ARCHIVAR** físicamente el expediente.

CÓPIESE NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

CARMEN MARITZA GONZALEZ MANRIQUE
Directora General ad hoc de la DIAN

Proyectó: Demetrio Augusto Parra Jiménez
Revisó: Demetrio Augusto Parra Jiménez
Aprobó: Carmen Maritza González M. – Directora General.